

1500094-80.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... o que configuraria de qualquer forma o tráfico. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas - sequer comprovado - não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500094-80.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-80.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO PEREIRA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. PAULO RICARDO PEREIRA FERREIRA, qualificado a fls. 19, foi denunciado e viu-se

processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 12 da Lei 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 6 de fevereiro de 2022, por volta da 2h30min, na Avenida 25, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria trazido consigo, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, vinte e nove porções de cocaína, contendo o preso líquido de 4,83 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, também sendo denunciado e processado porque nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua 42 nº 192, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca, possuiria no interior de sua residência quatro cartucho íntegros, de uso permitido, calibre .38, marca CBC, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado e outros dois indivíduos parados em um cruzamento na avenida 25.

Diante das circunstâncias, os policiais decidiram efetuar abordagem, vindo a apreender em poder do denunciado, no bolso de sua bermuda, 29 (vinte e nove) pinos de cocaína e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro.

Em seguida, os policiais pediram ao denunciado que apresentasse seus documentos de identificação, tendo ele informado que estavam em sua casa. Os milicianos, então, dirigiram-se com PAULO RICARDO até o imóvel e, após serem autorizados e ingressarem no local, localizaram dentro de um tênis 4 (quatro) munições calibre .38.”.

A denúncia de fls. 117/118 foi recebida em 11 de fevereiro de 2022 (fls. 119). O Réu foi citado a fls. 127, apresentando defesa preliminar em fls. 133/136, rejeitada a fls. 138/140. Na instrução da causa foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 181).

Em memoriais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 179/180).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação por falta de provas e, subsidiariamente, desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o do artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 182/186).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade de ambos os crimes está estampada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/05), boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09, auto de constatação preliminar de fls. 11/13, através da guia de depósito de fls. 110, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 154/156, por meio do laudo pericial de exame de munição (fls. 157/158), além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra o Réu que em Juízo negou o teor da denúncia, relatando que estava no cruzamento da 40 com a 25 juntamente com outras duas pessoas aguardando para comprar entorpecente para que fizessem uso, alegando que recebeu os vinte e nove pinos de cocaína do traficante, que seria conhecido por Piauí, mas não teve tempo de lhe pagar, porque os policiais chegaram e encontraram o entorpecente em seu bolso. Alega, ademais, que faria uso com os outros dois que estavam consigo, pagou toda a droga, mas sequer sabia o nome daqueles usuários que iria dividir o entorpecente. Na sequência, diz o depoente que foram até sua casa, porque estava sem documento e ali encontraram a munição na sapateira, o que lhe surpreendeu, porque não tinha nada antes e isso não era seu, desconhecendo quem teria deixado naquele local. Por fim, trabalha como cabeleireiro e é consumidor de cocaína, crack e maconha.

Sua versão não se sustenta e ficou isolada do contexto fático.

O policial militar José Roberto, em depoimento judicial, afirmou que estavam em patrulhamento pela Avenida 25 quando, no cruzamento, avistaram o Réu e outras duas pessoas, realizando a abordagem e naqueles dois nada de ilícito encontraram, ao passo que com o Acusado localizaram os pinos contendo cocaína e dinheiro trocado. Como o Réu não trazia documento, foram até sua casa e ali, com autorização, ingressaram, encontraram junto a um pé de tênis as quatro munições. O local em que o Acusado foi inicialmente abordado é conhecido pela traficância, assim como possuem conhecimento de que o Réu é traficante. Ademais, ele não aparentava estar sob efeito de drogas, sobre a munição o Réu confirmou que era dele, do mesmo modo que o entorpecente, tendo dito aos policiais, naquele momento, que iria vender.

A conduta do Acusado indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia consigo considerável quantidade de substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a quantidade de droga apreendida, a forma como estavam acondicionadas, não estar o Acusado sob efeito de drogas, o fato de que os policiais tinham ciência que ele era traficante, se encontrar em um conhecido ponto de venda de drogas, ter informado a eles, naquele momento, que o entorpecente seria vendido, assim como, não se pode ignorar, em Juízo, apesar de negar a acusação, o Réu acabou de informar que iria entregar a droga para duas pessoas que sequer sabia o nome, o que configuraria de qualquer forma o tráfico. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas - sequer comprovado - não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas, o que impede a desclassificação pretendida.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a Acusação se embasar somente no depoimento prestado por policial, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo porque não pode ser descartado. Não se verificam as contradições apontadas pela Defesa, que não desnaturaram os fatos tipificados na denúncia.

A condição funcional não o torna suspeito, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, "Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Lado outro, sobreleva destacar que a apreensão de munição consoma a prática do crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, não se exigindo que ela esteja acompanhada de arma de fogo, sob pena de interpretação contra legem, sendo que a negativa do Acusado não se sustenta porque a munição foi encontrada com seus pertences e ele não deu qualquer justificativa para o fato. A simples leitura do mencionado cânon já afasta qualquer exposição em sentido contrário: "Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa" (destaquei).

A conjunção alternativa ou, que une orações independentes, indica que são condutas distintas a posse de arma de fogo, acessório e munição, não necessitando que estejam todos juntos para que o delito se consume. A existência de arma de fogo municada serve para fins de dosimetria da pena, sendo que a simples localização de arma desmunicada ou somente acessório ou munição não tornam o fato atípico, por ser um crime de mera conduta.

Nesse panorama: "O atual diploma sobre armas equiparou a posse ou o porte de acessórios ou munição à arma de fogo, de modo que o sujeito que for surpreendido praticando qualquer uma das condutas anteriormente mencionadas em relação à munição de um armamento de uso restrito incidirá nas mesmas penas que aquele que transportar a própria arma municada. Nesses casos o princípio da ofensividade, segundo o qual somente existe crime quando se demonstra a efetiva lesão ou perigo de lesão do bem jurídico é aplicado excepcionalmente, apenas quando claramente for hipótese de crime impossível, o que aconteceria, por exemplo, na hipótese de munição inidônea a disparo ou arma obsoleta" (TJSP, Ap. 0003999-93.2012.8.26.0210, 13ª C.D.Crim., Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08.05.2014).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

No tocante ao delito do artigo 12 da Lei 10.826/03, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60 do Código Penal, muito embora portador de péssimos antecedentes, a pena não pode ser aumentada nesta fase para não incorrer em bis in idem com a reincidência, por serem as mesmas condenações, de forma que mantenho a pena em seu piso legal, uma vez que agiu com dolo normal do delito, ou seja, 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o Réu é multirreincidente (cf. fls. 41/42, processo nº 0000619-86.2017.8.26.0210; fls. 42, processo nº 0000758-04.2018.8.26.0210; fls. 42/43, processo nº 0001464-21.2017.8.26.0210; fls. 43, processo nº 0001503-18.2017.8.26.0210; e fls. 43, processo nº 0001541-30.2017.8.26.0210), circunstância agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal, exigindo a majoração da pena em ½ (metade) porque, muito embora jovem, demonstra inveterada persistência na prática de condutas criminosas, fixando a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em seu menor valor, à míngua de comprovação das condições financeiras do Acusado.

Fixo o regime inicial semiaberto, considerando os péssimos antecedentes do Acusado, que demonstra reiteração de condutas criminosas, não se verificando que o regime mais brando possa lhe favorecer. Do mesmo modo, inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis.

Quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, observo que o

Acusado é reincidente, demonstrando, assim, ter personalidade persistente na prática de condutas antissociais. Contudo, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal para não provocar um bis in idem com a agravante da reincidência. Sendo assim, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, onde não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase aumento sua pena em $\frac{1}{2}$ (metade) em razão da multirreincidência acima mencionada, incluindo reincidência específica (cf. fls. 41/42, processo nº 0000619-86.2017.8.26.0210 e fls. 42, processo nº 0000758-04.2018.8.26.0210), atingindo o patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Justifico esta fração tendo em vista que o Réu, apesar de jovem, ostenta várias condenações transitadas em julgada, inclusive por crimes equiparados ao hediondo, demonstrando, na persistência na prática de condutas antissociais, total falta de comprometimento frente a sociedade, a exigir maior vigor estatal na imposição da pena.

Sendo reincidente, até mesmo específico, o Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras, sendo que o regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, por expressa disposição do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou a substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos objetivo (ele é reincidente) e subjetivo. Ressalto, quanto a este requisito subjetivo que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada ao crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais

gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).

E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Ademais tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizada quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo (fls. 110), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto os crimes apurados são classificados como vagos, assim entendido aqueles que têm por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes (artigo 69, caput, do Código Penal), posto que o Réu praticou duas condutas com dois resultados distintos, ele está condenado ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa, no menor valor (cf. artigo 72 do Código Penal), sendo vedado, para ambos, a substituição da privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis .

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro, além de objetos relacionados ao crime, inclusive um automóvel (cf. fls. 14/18 e 59), evidenciando-se ser vinculado ao comércio de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda destes bens e valores apreendidos com o Réu, que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu PAULO RICARDO PEREIRA FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 12 da Lei 10.826/03, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda dos bens e valores apreendidos com ele (cf. fls. 110) em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como se encaminhe o numerário apreendido em fls. 110 em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que preso em flagrante fosse posto em liberdade depois de condenado inclusive em crime assemelhando ao hediondo.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA